AUTO

Superintendencia de Sociedades **Bogotá, D.C.**

Partes
Olga Cecilia del Castillo

contra

Compañía de Promociones Internacionales de Servicios de Salud (Soprinsa) S.A.

Asunto
Artículo 133 de la Ley 446 de 1998

Trámite
Proceso verbal sumario

I. Antecedentes

1. El 5 de marzo de 2013, Olga Celia del Castillo, por conducto de apoderado especial, presentó una demanda en contra de Compañía de Promociones Internacionales de Servicios de Salud S.A. –Soprinsa S.A.- (en adelante 'Soprinsa'), a fin de que este Despacho reconozca la configuración de los presupuestos que dan lugar a la sanción de ineficacia respecto de diversas decisiones adoptadas por la asamblea general de accionistas de la sociedad demandada.

2. La demandante solicitó, además, el decreto de una medida cautelar consistente en la inscripción de la demanda en el registro mercantil que lleva la Cámara de Comercio de Bogotá, conforme a lo previsto en el artículo 590 del Código General del Proceso.

II. Consideraciones del Despacho

En el curso de múltiples pronunciamientos, este Despacho ha desarrollado algunos presupuestos para determinar la procedencia de medidas cautelares en el ámbito de conflictos societarios.[1] Tales presupuestos han sido derivados de lo previsto en el artículo 590 del Código General del Proceso, así como de la aplicación de esta norma a los diversos casos sometidos a consideración de esta Delegatura. Es así como, para decretar una medida cautelar de la naturaleza solicitada, debe efectuarse un cuidadoso análisis de los elementos de juicio disponibles, a fin de analizar las probabilidades de éxito de la demanda y evaluar el interés del demandante, según se expresa a continuación.

1. Las probabilidades de éxito de las pretensiones formuladas en la demanda

El primero de los presupuestos mencionados consiste en un examen preliminar de los diferentes elementos de juicio disponibles, para efectos de

[1] Cfr. Auto No. 801-002289 del 20 febrero 2013; Auto No. 800-016014 del 19 noviembre 2012; Auto No. 801-014531 del 17 octubre 2012; Auto No. 801-013957 del 4 octubre 2012 y Auto No. 801-012437 del 3 septiembre 2012. Las providencias mencionadas pueden consultarse en la sección de jurisprudencia de la página de la Superintendencia de Sociedades, disponible en la siguiente dirección: www.supersociedades.gov.co/pmercantiles.html

determinar, con alguna precisión, las probabilidades de éxito de las pretensiones formuladas por el demandante. Este presupuesto se deriva de la denominada apariencia de buen derecho a que alude el artículo 590 del C.G.P. La apariencia de buen derecho ha sido referida a 'la carga de acreditar de forma provisional e indiciaria, que la pretensión […] presenta visos de poder prosperar; [es preciso establecer] una probabilidad cualificada de éxito de la pretensión principal que se pretende cautelar'.[2]

Este análisis preliminar no conlleva, en forma alguna, un prejuzgamiento que le impida al juez pronunciarse más adelante acerca del fondo del asunto.[3] Al tratarse de una valoración previa de las pruebas disponibles cuando se solicita la medida cautelar, es perfectamente factible que, al momento de dictar sentencia, el juez llegue a una conclusión diferente de la expresada en el auto de medidas cautelares. En efecto, durante el curso del proceso pueden surgir elementos de juicio que le resten fuerza a los argumentos empleados por el juez para aceptar o rechazar la cautela. En criterio de Bejarano Guzmán, 'no se trata de una decisión de fondo sino preliminar, que por supuesto puede ser modificada en la sentencia que le ponga fin al proceso […] si el juez no decreta la [medida] en modo alguno ello significa que la sentencia será adversa al demandante, pues las pruebas recaudadas en el proceso pueden contribuir a cambiar la decisión que se adopte en la sentencia'.[4]

Con fundamento en las anteriores precisiones, el Despacho analizará la solicitud presentada por el demandante respecto de la inscripción de la demanda en el registro mercantil. Para el efecto, se hará una breve descripción de la prohibición contenida en el artículo 185 del Código de Comercio, así como de su aplicación respecto de administradores que ostenten la calidad de suplentes.

A. La prohibición del artículo 185 del Código de Comercio

Entre las múltiples restricciones establecidas en nuestro ordenamiento societario respecto de la actividad de los administradores sociales, se encuentra la prevista en el artículo 185 del Código de Comercio. Esta norma les impone a tales funcionarios la prohibición de representar acciones que no sean de su propiedad en las reuniones del máximo órgano social, a menos que lo hagan en calidad de representantes legales de algún accionista. Según el texto del citado artículo 185, 'salvo los casos de representación legal, los administradores y empleados de la sociedad no podrán representar en las reuniones de la asamblea o junta de socios acciones distintas de las propias […]'.[5]

---

[2] J Garnica Martín, 'Medidas Cautelares en el Proceso de Impugnación de Acuerdos Sociales' en Órganos de la Sociedad de Capital, Tomo I (2008, Valencia, Tirant Lo Blanch) 580.

[3] En opinión de Garnica Martín, 'resulta imposible enjuiciar adecuadamente la existencia del *fumus* sin emitir ese prejuicio. Si se quiere evitar prejuzgar lo que en realidad se consigue es dejar de enjuiciar con seriedad la apariencia de buen derecho (…)'. Y, más adelante, agrega lo siguiente: 'ello no tiene por qué significar que el juez que ha emitido un juicio previo haya perdido su imparcialidad: ambos juicios versan sobre lo mismo pero no se emiten a partir de los mismos elementos probatorios, por lo que no es difícil que pueda cambiar la visión del juez que dictó medidas cautelares sobre el asunto cuando dicta sentencia' (2008) 580.

[4] R Bejarano Guzmán, Procesos Declarativos, Ejecutivos y Arbitrales, 5ª Edición (2011, Bogotá, Editorial Temis) 167. Cfr. también a HF López Blanco, Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano, Tomo II: Parte Especial, 7ª Edición (1999, Bogotá, Dupré Editores) 149.

[5] Esta limitación de orden legal busca evitar que 'los administradores formen mayorías propias que hagan nugatorio el derecho de los demás socios a examinar y controlar el desarrollo del contrato social y la conducta de los administradores' G Pinzón, Sociedades Comerciales, Volumen I: Teoría General, 5ª Edición (1988, Bogotá, Editorial Temis) p. 189.

También es relevante resaltar que la restricción en comento recae, exclusivamente, sobre los administradores que estén en ejercicio de sus cargos. Es claro, en este orden de ideas, que 'si dichas personas no están ejerciendo sus cargos o se retiran de ellos, pueden entrar a ejercer válidamente el poder que les haya sido conferido'.[6] Esta aclaración es de la mayor importancia para los efectos del presente auto, debido a que varias de las pretensiones formuladas en la demanda están relacionadas con la participación de un miembro suplente de la junta directiva de Soprinsa S.A. como representante de dos accionistas de la compañía, en diversas reuniones del máximo órgano social. Es así como la aludida prohibición tan sólo podrá hacerse efectiva respecto de aquellos suplentes que, dentro del período para el cual fueron designados, ejercieron labores de administración en reemplazo de las personas que ocupan los cargos principales.

Esta última afirmación encuentra sustento en múltiples pronunciamientos emitidos por esta entidad. En el Oficio No. 220-10136 del 30 de marzo de 2001 se expresó, por ejemplo, que 'cualquier actuación de un miembro suplente de la junta directiva en las decisiones de este órgano social, supone obviamente el ejercicio efectivo del cargo que lo ubica dentro de la prohibición legal consagrada en el artículo 185 citado y por tanto queda impedido para representar acciones distintas de las propias, sin que circunstancia alguna como el hecho de haber actuado solo una vez o el de haber decidido una sola propuesta, configuren excepciones al referido precepto normativo'. También puede consultarse, en idéntico sentido, en el Oficio No. 220-002481 del 15 de enero de 2002, en el cual se dejó claro que la prohibición del artículo 185 'es aplicable en el evento en que el miembro de la junta directiva actúe como principal'. En ese mismo oficio, esta Superintendencia hizo referencia, en los siguientes términos, a las consecuencias derivadas de la violación de lo previsto en la norma citada: 'De haberse incurrido en la anterior prohibición, […] debe procederse a descontar de las reuniones, en nuestro caso, de la junta de socios, las cuotas indebidamente representadas y poder así determinar si una vez restadas las mismas, las sesiones en las cuales actuó el apoderado (miembro de la junta directiva) se configuró debidamente el quórum'.

Así las cosas, le corresponde ahora al Despacho estudiar, en forma preliminar y con base en las pruebas disponibles en esta etapa del proceso, si en el presente caso pudo haberse infringido la prohibición a que alude el artículo 185 del Código de Comercio. Este análisis estará acompañado de algunas consideraciones acerca de los efectos de una posible violación de la norma citada respecto de las decisiones asamblearias objeto de la demanda. En otras palabras, el Despacho se ocupará en establecer si la posible representación indebida de ciertos accionistas pudo haber dado lugar a la ineficacia de algunas de las decisiones adoptadas por el máximo órgano de Soprinsa S.A.

B. Análisis preliminar del caso presentado por la demandante

Las pretensiones formuladas en la demanda están orientadas a que este Despacho reconozca la configuración de los presupuestos que dan lugar a la sanción de ineficacia, respecto de múltiples decisiones adoptadas por la asamblea general de accionistas de Soprinsa S.A. Para efectos de estimar si tales pretensiones son lo suficientemente meritorias como para decretar la medida cautelar solicitada, a continuación se expone un análisis preliminar acerca de lo transcurrido durante cada una de las reuniones en las que se aprobaron las decisiones controvertidas.

[6] Id.

(i) Decisiones adoptadas durante la reunión ordinaria de la asamblea general de accionistas de Soprinsa S.A. celebrada el 31 de marzo de 2008 (acta No. 106AG).

Según lo consignado en el acta No. 105AG, durante la reunión ordinaria de la asamblea general de accionistas de Soprinsa S.A. celebrada el 23 de marzo de 2007, Antonio José del Castillo fue designado como miembro de la junta directiva de Soprinsa S.A., en calidad de suplente personal de Nicolás Guérrico Echeverría (vid. Folio 169 del expediente). A la luz del artículo vigésimo tercero de los estatutos de la compañía, debe entenderse, en principio, que esta designación se hizo por el término de un año, es decir, hasta el 23 de marzo de 2008. (vid. Folio 276).

El señor del Castillo participó en las reuniones de la junta directiva celebradas el 11 de mayo de 2007 (vid. Acta No. 105JD, Folio 172) y el 26 de julio de 2007 (vid. Acta No. 107JD, Folio 173), en reemplazo de Nicolás Guérrico Echeverría. Según consta en las aludidas actas, el señor del Castillo ejerció su derecho de voto como miembro de la junta directiva, a fin de autorizar al representante legal para solicitar un crédito bancario y aprobar los estados financieros consolidados de la compañía (vid. Folios 172 y 174).

La participación de Antonio José del Castillo en las aludidas reuniones, durante las cuales actuó en propiedad como miembro de la junta directiva de Soprinsa S.A., muy probablemente lo hizo sujeto del régimen de deberes y prohibiciones previsto en nuestro ordenamiento para los administradores sociales. De igual forma, a pesar de que el período para el cual fue designado el señor del Castillo expiraba el 23 de marzo de 2008, no puede perderse de vista que, conforme a lo previsto en el artículo vigésimo tercero de los estatutos de Soprinsa S.A., 'aun cuando se hayan vencido sus períodos, los miembros de la Junta Directiva y sus suplentes seguirán ocupando sus cargos hasta que la Asamblea haga nueva elección'. Es decir que los directores elegidos el 23 de marzo de 2007, incluido Antonio José del Castillo, continuaron en ejercicio de sus funciones hasta el momento en que los accionistas de Soprinsa S.A. eligieron a la junta directiva de la compañía el 31 de marzo de 2008.

Así las cosas, los elementos probatorios disponibles en esta etapa del proceso apuntan a que Antonio José del Castillo se encontraba sujeto a la prohibición consagrada en el artículo 185 del Código de Comercio cuando representó las acciones de Cidesal S.A. y Phrodinka XXI S.L., durante la reunión ordinaria de la asamblea general de accionistas de Soprinsa S.A. del 31 de marzo de 2008. De ser ello cierto, las decisiones adoptadas durante esta reunión habrían sido posiblemente ineficaces, por no encontrarse debidamente representados los accionistas que, para la época, eran titulares de acciones equivalentes al 71.617% del capital suscrito de Soprinsa S.A. En otras palabras, de verificarse la indebida representación de tales accionistas, el máximo órgano social no habría contado con quórum suficiente para deliberar durante la sesión del 31 de marzo de 2008.

(ii) Decisiones adoptadas durante la reunión ordinaria de la asamblea general de accionistas de Soprinsa S.A. celebrada el 31 de marzo de 2009 (acta No. 117AG).

Durante la reunión ordinaria de la asamblea general de accionistas de Soprinsa S.A. celebrada el 31 de marzo de 2008, Antonio José del Castillo fue designado nuevamente como miembro de la junta directiva de Soprinsa S.A., en calidad de suplente personal de Nicolás Guérrico Echeverría (vid. Folio 179 del expediente), hasta el 31 de marzo de 2009.

Si bien el señor del Castillo asistió a las reuniones de la junta directiva celebradas el 14 de abril de 2008 (vid. Acta No. 109JD, Folio 180) y el 3 de octubre 2008 (vid. Acta No. 111JD, Folio 183), en ambas oportunidades participó Nicolás Guérrico Echevarría, en calidad de director principal. En este sentido, no consta en el texto de las actas citadas que el señor del Castillo hubiese actuado como director durante tales reuniones, en reemplazo del señor Guérrico. Así, pues, no se han aportado pruebas que permitan constatar que el señor del Castillo hubiese efectivamente ejercido la potestad de miembro de la junta directiva de Soprinsa S.A. durante el período comprendido entre el 31 de marzo de 2008 y el 31 de marzo de 2009. Esto significa, en principio, que el señor del Castillo no habría estado inhabilitado para representar las acciones de Cidesal S.A. y Phrodinka XXI S.L. durante la reunión del máximo órgano social del 31 de marzo de 2009.

Con todo, esta conclusión sería bien diferente si las decisiones adoptadas durante la reunión del 31 de marzo de 2008 hubiesen sido ineficaces, en los términos explicados en el acápite anterior. Bajo esta hipótesis, la determinación consistente en elegir a los miembros de la junta directiva de Soprinsa S.A. para el período 2008-2009 no habría surtido ningún efecto. Por este motivo, continuarían en sus cargos los directores elegidos durante la reunión de asamblea del 23 de diciembre de 2007, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo vigésimo tercero de los estatutos de la compañía. De ser éste el caso, Antonio José del Castillo habría estado sujeto a la prohibición del artículo 185 del Código de Comercio cuando representó las acciones de Cidesal S.A. y Phrodinka XXI S.L. durante la reunión ordinaria del máximo órgano social de Soprinsa S.A correspondiente al año 2009. Por consiguiente, de haber sido ineficaces las decisiones adoptadas el 31 de marzo de 2008, también lo serían las aprobadas durante la reunión del 31 de marzo de 2009. Ello obedece a que, al estar Antonio José del Castillo cobijado por la prohibición del artículo 185, no habría podido fungir como apoderado de Cidesal S.A. y Phrodinka XXI S.L., propietarias de acciones equivalentes al 71.617% del capital suscrito de Soprinsa S.A. Es claro, en todo caso, que la determinación final acerca de tales asuntos sólo podrá emitirse al final del presente proceso, cuando el Despacho cuente con la totalidad de los elementos de juicio requeridos para el efecto.

(iii) Decisiones adoptadas durante la reunión ordinaria de la asamblea general de accionistas de Soprinsa S.A. celebrada el 24 de marzo de 2010 (acta No. 118AG).

El análisis correspondiente a las decisiones adoptadas el 24 de marzo de 2010 guarda relación con lo expresado en los párrafos anteriores. Durante la reunión ordinaria de la asamblea general de accionistas de Soprinsa S.A. del 31 de marzo de 2009, Antonio José del Castillo fue designado, una vez más, como miembro de la junta directiva de Soprinsa S.A., en calidad de suplente personal de Nicolás Guerrico Echeverría (vid. Folio 179 del expediente), hasta el 31 de marzo de 2010. El señor del Castillo participó en las reuniones de la junta directiva celebradas el 11 de agosto de 2009 (vid. Acta No. 117JD, Folio 195), el 25 de febrero de 2010 (vid. Acta No. 117-A JD, Folio 196) y el 12 de marzo de 2010 (vid. Acta No. 118 JD, Folio 199), durante las cuales ejerció su potestad como director de Soprinsa S.A., en reemplazo de Nicolás Guérrico Echeverría.

Así, pues, por las razones ya expuestas, Antonio José del Castillo parece haber estado sujeto a la prohibición del artículo 185 del Código de Comercio para la fecha en que se celebró la reunión ordinaria de la asamblea de Soprinsa S.A.

del 24 de marzo de 2010. De aceptarse esta interpretación, habrían sido ineficaces las decisiones adoptadas durante esta reunión, en tanto en cuanto el señor del Castillo representaba a Cidesal S.A. y Phrodinka XXI S.L., titulares del 71.617% del capital suscrito de Soprinsa S.A.

Por lo demás, si se configuró la ineficacia de las decisiones adoptadas por la asamblea general el 31 de marzo de 2008 y el 31 de marzo de 2009, podría predicarse también esta sanción respecto de las decisiones del 24 de marzo de 2010. Esta afirmación encuentra fundamento en el hecho de que, de ser ineficaces los nombramientos de junta directiva efectuados en los años 2008 y 2009, continuaría en ejercicio la junta designada en el 2007, de la cual formaba parte Antonio José del Castillo y durante cuya vigencia actuó en reemplazo de Nicolás Guérrico Echeverría.

(iv) Decisiones adoptadas durante la reunión ordinaria de la asamblea general de accionistas de Soprinsa S.A. celebrada el 28 de marzo de 2011 (acta No. 126AG).

El anterior análisis de lo transcurrido el 24 de marzo de 2010 es igual al que le corresponde a las decisiones adoptadas por el máximo órgano de Soprinsa S.A. durante la reunión ordinaria celebrada el 28 de marzo de 2011. En la primera de las reuniones citadas fue designado Antonio José del Castillo como miembro suplente de Nicolás Guérrico Echeverría para el período 2010-2011. El señor del Castillo participó en las reuniones de la junta directiva celebradas el 28 de junio de 2010 (vid. Acta No. 119JD, Folio 203), el 15 de julio de 2010 (vid. Acta No. 120 JD, Folio 204), el 6 de septiembre de 2010 (vid. Acta No. 121 JD, Folio 205), el 30 de septiembre de 2010 (vid. Acta No. 122 JD, Folio 206), el 10 de diciembre de 2010 (vid. Acta No. 123 JD, Folio 206) y el 24 de enero de 2011 (vid. Acta No. 124 JD, Folio 207), en reemplazo de Nicolás Guérrico Echeverría. Durante tales reuniones, el señor del Castillo aprobó múltiples decisiones, en calidad de director de Soprinsa S.A.

Antonio José del Castillo también representó las acciones de propiedad de Cidesal S.A. y Centauro Capital S.L., titulares del 71.617% del capital suscrito de Soprinsa S.A., durante la reunión de asamblea del 28 de marzo de 2011. Sin embargo, para esta fecha, el señor del Castillo posiblemente estuvo sometido a la prohibición contenida en el artículo 185 del Código de Comercio, bien porque ejerció como director de Soprinsa S.A. durante el período para el cual fue elegido como suplente de Nicolás Guérrico Echeverría (2010-2011) o debido a la posible ineficacia de las elecciones de junta efectuadas en los años 2008, 2009 y 2010.

(v) Decisiones adoptadas durante la reunión extraordinaria de la asamblea general de accionistas de Soprinsa S.A. celebradas el 11 de julio de 2011 (acta No. 129 AG), el 11 de enero de 2012 (acta No. 131 AG) y el 23 de febrero de 2012 (acta No. 133 AG).

El fundamento de las pretensiones de la demanda en cuanto a las decisiones del 11 de julio de 2011, 11 de enero de 2012 y 23 de febrero de 2012, se deriva de la participación de dos administradores, Iñigo Gómez-Pineda Goizueta y Nicolás Guérrico Echeverría, como representantes de las acciones de propiedad de Cidesal S.A. y Clonfert S.A. durante las tres reuniones indicadas.[7]

[7] Según se expresa en la demanda, el señor Gómez-Pineda, además de desempeñarse como presidente de Soprinsa S.A. desde el 30 de marzo de 1995, era miembro principal de la junta directiva de la demandada—al igual que Nicolás Guérrico Echeverría—en las fechas en que se celebraron las reuniones mencionadas en el texto principal.

Según el criterio del demandante, tales administradores estaban inhabilitados para participar como apoderados de las citadas compañías, por encontrarse incursos en la prohibición del artículo 185 del Código de Comercio. En este orden de ideas, al tratarse de reuniones de quórum universal celebradas sin previa convocatoria, las decisiones allí adoptadas adolecerían de ineficacia, por la representación indebida de Cidesal S.A. y Clonfert S.A. Debe resaltarse que el material probatorio aportado con la demanda permite verificar algunos de los hechos reseñados, es decir, que se trató de reuniones de quórum universal sin previa convocatoria (vid. Folios 219, 224 y 235), que Iñigo Gómez-Pineda Goizueta y Nicolás Guérrico Echeverría eran administradores principales de Soprinsa S.A. para la fecha de las reuniones indicadas (vid. Folios 441, 442 y 487) y que representaron allí las acciones de Cidesal S.A. y Clonfert S.A. (vid. Folios 219, 220, 224 y 235).

(vi) Resultado del análisis preliminar

A la luz de las anteriores precisiones, el Despacho debe concluir que, en esta etapa del proceso, la demandante ha acreditado con mérito que las probabilidades de éxito de sus pretensiones justifican la práctica de la medida cautelar solicitada. Por supuesto que la determinación final sobre los asuntos debatidos en el presente litigio sólo se producirá en el momento de dictar sentencia, una vez el Despacho cuente con la totalidad de los elementos probatorios pertinentes. En todo caso, para los efectos de este Auto, debe considerarse cumplido uno de los presupuestos principales requeridos para decretar una medida cautelar, es decir, la apariencia de buen derecho a que alude el artículo 590 del C.G.P.

2. El interés del demandante

El apoderado de la demandante ha solicitado la práctica de la medida cautelar con el fin de ‘proteger el derecho objeto del litigio, impedir su infracción y, sobre todo, prevenir daños a los accionistas y a terceros’. Debe resaltarse, en este sentido, que en la demanda no se ofrece una descripción detallada de las razones que le sirven de sustento a las anotadas justificaciones. En todo caso, tras una revisión del expediente, este Despacho pudo constatar que la demandante cuenta con un interés económico legítimo en este proceso. En verdad, la ineficacia de algunas de las decisiones controvertidas—aprobaciones de proyectos de distribución de utilidades, reformas estatutarias y de estados financieros de fin de ejercicio—podría llegar a afectar el monto de las utilidades repartibles de la compañía. Por consiguiente, este Despacho considera acreditado que el interés económico de la demandante, en su calidad de accionista de Soprinsa S.A., es suficiente para justificar el decreto de la medida cautelar solicitada.

3. La caución

Antes de que se decrete la medida cautelar solicitada, deberá prestarse una caución, en los términos previstos en el Código de Procedimiento Civil y el Código General del Proceso. Con todo, para efectos de fijar el monto correspondiente, es necesario efectuar un breve repaso de la regulación prevista en nuestro ordenamiento sobre la materia.

Si bien en el artículo 590 del Código General del Proceso se establece que la caución debe ser ‘equivalente al 20% de las pretensiones estimadas en la demanda’, el demandante no le ha asignado un valor económico a sus

pretensiones. No obstante, el mismo artículo 590 dispone también que 'el juez, de oficio o a petición de parte, podrá aumentar o disminuir el monto de la caución cuando lo considere razonable'. Este Despacho cuenta entonces con alguna discreción para fijar de la cuantía correspondiente a la caución. No quiere ello decir, por supuesto, que pueda establecerse esta cuantía en forma arbitraria. De conformidad con lo expresado por la Corte Constitucional, 'en la mayoría de los casos [el legislador] ha dejado [la] determinación [de la cuantía de la caución] a la discrecionalidad de los jueces responsables de su aplicación, bajo los criterios de proporcionalidad y razonabilidad'.[8] Ello quiere decir que la suma que se fije para el efecto deberá, en todos los casos, obtenerse como resultado de un cuidadoso análisis. Así, pues, este Despacho ha considerado que, para fijar el valor de la caución, es indispensable tener en cuenta los efectos derivados de la medida, así como la estimación de las probabilidades de éxito de la demanda.

El cálculo del valor de la caución parte de la estimación de los posibles perjuicios derivados de la medida cautelar.[9] En este sentido, por referirse la demanda a una multiplicidad de decisiones adoptadas por la asamblea de Soprinsa S.A. entre 2008 y 2012, no es verosímil cuantificar, en forma exacta, la magnitud de los perjuicios que podría generarle a la sociedad demandada la práctica de la medida cautelar solicitada por la demandante. En todo caso, debe recordarse que esa medida consiste en la simple inscripción de la demanda en el registro mercantil que lleva la Cámara de Comercio de Bogotá. Aunque la posible ineficacia de las decisiones objeto de este litigio podría interrumpir, en forma traumática, el normal funcionamiento de Soprinsa S.A., este Despacho no encontró en el expediente prueba alguna de que la simple inscripción de la demanda pudiera llegar a generarle mayores perjuicios a la compañía demandada. Por este motivo, el Despacho usará como factor de cómputo para establecer el monto de la caución un porcentaje del 0.01% aplicado sobre las utilidades netas de Soprinsa S.A. para el año 2012 (vid. Folio 251), lo cual arroja una cifra de $259.374.628.

De otra parte, en varias oportunidades este Despacho ha recurrido al expediente de usar las probabilidades de éxito de la demanda como un factor para graduar el monto de la caución. Se trata de una simple relación inversamente proporcional, por cuyo efecto, entre mayores sean las probabilidades de éxito, menor será el valor de la caución. Esta fórmula encuentra justificación en el hecho de que la caución sólo se hace efectiva cuando no prosperan las pretensiones del demandante.[10] Así, por virtud de las consideraciones efectuadas en el acápite correspondiente, este Despacho estima necesario reducir el valor ya estimado de la caución a la suma de $51.874.925.[11]

---

[8] Sentencia C-523 de 2009.

[9] Así, por ejemplo, en el Auto No. 801-015217 del 31 octubre 2012, este Despacho señaló lo siguiente: 'La suma que se fije para el efecto deberá, en todos los casos, obtenerse como resultado de un análisis orientado a estimar los posibles perjuicios que podrían derivarse de la suspensión del acto impugnado'.

[10] Según lo expresado por Garnica Martín, 'la fortaleza de la apariencia de buen derecho es un factor determinante del importe de la caución, y es razonable que lo sea, dado que es un factor directamente indicativo del riesgo de que se produzcan los daños y perjuicios que se pretenden garantizar'. J Garnica Martín, (2008) 584.

[11] Este ajuste no significa que se le haya asignado a las pretensiones de la demanda unas probabilidades de éxito del 80%. Los cálculos efectuados en el texto principal se derivan de simples estimaciones, basadas en una aproximación preliminar a los documentos que se han aportado en esta temprana etapa del proceso.

Por virtud de lo expuesto, el Superintendente Delegado para Procedimientos Mercantiles,

RESUELVE

Primero. Fijar una caución por la suma de $51.874.925, la cual deberá ser prestada por el demandante bajo cualquiera de las modalidades previstas en la ley para el efecto, dentro de los 10 días siguientes a la notificación del presente auto. El decreto y práctica de la medida cautelar aquí descrita estará sujeto a la condición de que el demandante preste la caución a que se ha hecho referencia.

Segundo. Una vez prestada la caución en forma debida, ordenar la inscripción de la demanda presentada por Olga Cecilia del Castillo en contra de Soprinsa S.A. en el registro mercantil que lleva la Cámara de Comercio de Bogotá.

Tercero. Una vez prestada la caución en forma debida, oficiarle a la Cámara de Comercio de Bogotá, por el medio más expedito, para que proceda de conformidad con lo ordenado por este Despacho.

Cuarto. Una vez prestada la caución en forma debida, informarle al representante legal de Soprinsa S.A., por el medio más expedito, acerca de la medida cautelar ordenada por este Despacho.

Notifíquese y cúmplase.

El Superintendente Delegado para Procedimientos Mercantiles,

José Miguel Mendoza
Nit: 800.125.872 Trámite: 170001
Exp: 27752 Código Dep: 801
Rad:2013-01-060693
M6866